

1501756-53.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... a sua coautoria ou participação no tráfico de drogas, ou no crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Assim, não é possível a condenação dos réus Marcos e Ronaldo por falta de provas da sua conduta delitiva, em primazia ao princípio constitucional da presunção da inocência e do "in dubio pro reo". Impõe-se, pois, a absolvição desses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501756-53.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501756-53.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187386/2019 - DEL.POL.ARUJA, 6018969 - DEL.POL.ARUJA, 2420/19/201 - DEL.POL.ARUJA, 2187386 - DEL.POL.ARUJA, 2420/19/201 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Vistos.

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL, RONALDO AUGUSTO GONÇALVES MARIANO e IKARO CHAMARELLI, qualificados nos autos às fls.23; 37 e 46, respectivamente, foram denunciados e regularmente processados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Consta da denúncia (fls. 236/241) que, em data não determinada até 23h30min do dia 26/06/2019, os acusados se associaram entre si, bem como a indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas,

mediante divisão de tarefas. Consta também que no dia 26/06/2019, por volta das 23h30min, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 204 + 500 Jardim Emília, nesta cidade de Arujá/SP, os acusados, agindo em concurso e unidade de propósitos, transportavam e guardavam drogas, consistentes em 04 tijolos de maconha, com peso aproximado de 2,2kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com o fim de entregar a consumo de terceiros.

Notificados (cf. fls. 384, 385 e 387), os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 182/183 e 237/240). Em seguida, a denúncia foi recebida pelo Juízo (fls. 410), designando-se audiência de instrução e julgamento do feito.

Termo de audiência às fls. 667/668 e 676/682, em que foram os réus interrogados e a testemunha Marcelo Vantini prestou depoimento. No termo de audiência às fls. 815/817 consta a oitiva da testemunha Fred Henrique.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição dos acusados Marcos Roberto dos Santos Pimentel e Ronaldo Augusto Gonçalves Mariano das imputações dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e absolvição do acusado IKARO CHAMARELLI apenas quanto ao artigo 35 da Lei nº 11.343/06. No mais, requereu a condenação do réu IKARO CHAMARELLI ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia (fls. 973/987).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus Ronaldo e Marcos de ambos os crimes; bem como a absolvição do réu Ikaro do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e a desclassificação da imputação prevista no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a droga que transportava era para consumo próprio (fls. 991/998).

É o relatório.

II-FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Com relação aos réus Marcos Roberto e Ronaldo Augusto não há prova inequívoca acerca da materialidade e autoria dos crimes que lhe são imputados.

As testemunhas de acusação não conseguiram atestar inequivocamente que estes réus eram os responsáveis pela droga encontrada dentro do veículo, não se podendo afirmar que estes réus transportavam, guardavam a droga ou até mesmo se contribuíram para arremessar a droga pela janela do veículo enquanto estavam sendo perseguidos pela polícia. Aliás, as testemunhas de acusação não se recordavam se estes réus assumiram a responsabilidade no momento da abordagem.

Em juízo, a testemunha Fred Henrique, policial rodoviário federal, disse que se recorda dos réus presentes. Estavam trabalhando na praça de rodagem de Arujá. Foi dada a ordem de parada a um Fiat Strada, mas se recusaram e começaram a fuga e no meio do caminho jogaram os tijolos da droga pela janela do passageiro. Nessa noite estavam trabalhando com duas viaturas, a viatura que estava mais próxima não perdeu o contato com o veículo e a segunda parou para recolher os tijolos de maconha que foram jogados. Em nenhum momento o veículo foi perdido de vista. Era um tamanho razoavelmente grande. Somente foram recolhidos 4 tijolos, mas não se sabe se jogaram mais. Eles pararam depois de alguns quilômetros e a viatura que estava mais próxima fez a abordagem. Não tinha droga no veículo, mas dinheiro, em torno de R\$1.000,00. A testemunha estava na viatura de trás, recolhendo. Posteriormente conversou com os réus. Não se lembra do que eles falaram, se confirmaram ou não. Em juízo, a testemunha Marcelo Vantini dos Santos, policial rodoviário federal, disse que reconhecia os réus. Estavam fazendo o comando no Pedágio de Arujá, Km 204 na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando deram ordem de parada

para o veículo onde estavam os réus, sendo que estes desrespeitaram a ordem de parada e empreenderam fuga. Alegou que, cerca de um quilometro à frente, os réus começaram a arremessar pela janela do passageiro alguns objetos, que foram recolhidos por uma das viaturas, enquanto a outra permanecia na perseguição. Afirmou que o carro dos réus adentrou o Município de Arujá, onde foi abordado. A outra viatura recolheu os objetos encontrados e constatou que se tratava de maconha. Afirmou que Ikaro estava conduzindo o veículo automotor. Narrou que, no momento da abordagem, o condutor do veículo (Ikaro) falou que foi para São Paulo pegar uma hélice de barco e, se ele não se engana, iria para Ilhabela, e quando perguntou onde estaria a peça para o condutor, não recebeu resposta e, por isso, deu a ordem para que Ikaro parasse o veículo para uma vistoria e, logo em seguida, este empreendeu fuga. Informou que não se recorda de ter encontrado nenhuma hélice de barco nem que tenha encontrado qualquer nota fiscal de qualquer coisa relacionada a barco. Informou que não dava para saber quem arremessou os objetos pela janela, mas que saiu da janela do passageiro. Não viram se os réus jogaram roupas pela janela, somente as drogas. Também não se recorda se tinha encontrado várias roupas nos carros. Informou que tudo o que ele tinha encontrado no veículo fora apreendido, e apresentado juntamente com o veículo. O horário da abordagem foi no período noturno. Esclareceu que, como estava na viatura de trás, ele foi o responsável por recuperar os quatro tijolos de maconha que foram arremessados na estrada, e não por apreendê-los na cidade de Arujá. Informou que recuperou quatro tijolos de maconha. Informou que a equipe do depoente, que foi responsável pelo recolhimento das drogas, chegou logo depois de os três réus terem sido abordados pela outra equipe, já estavam fora do carro. Não se recorda o que conversou com os réus neste momento. Não se recorda de ter encontrado nenhum valor em espécie no veículo automotor. Esclareceu que foi a equipe dele que apreendeu os celulares deles, mas não se recorda da quantidade exata que foi apreendida. O passageiro que estava na parte de trás do veículo teria dito que só estava lá pegando uma carona, sendo que ele não se recorda o nome de quem era, achando se tratar de Ronaldo. Apenas se recorda que o motorista Ikaro estaria levando a droga para Ilhabela, mas não se lembra nem do local onde eles adquiriram a droga nem a quantidade que pagaram por ela. Afirmou que nenhum deles relatou ser usuário de drogas. Em juízo, o réu Marcos Roberto dos Santos Pimentel disse que conheceu Ikaro em 2015 na prisão, criando laços de amizade com ele. Afirmou que saiu da prisão em 2019 e encontrou o Ikaro no facebook, aduzindo que pretendia ir até Ilhabela para ver a filha mais nova que mora naquela cidade, mas, como tinha acabado de sair da penitenciária, não tinha condições de pagar condução para ir até lá. Ikaro lhe informou que poderia dar carona até Ilhabela, já que informou que às vezes ia até São Paulo. Disse que estava usando o celular de sua filha e marcou com o Ikaro de pegá-lo no Jabaquara. Assim que entrou dentro do carro do Ikaro, este lhe informou pegaria uma outra pessoa na Vila Mariana, que, no caso, seria o réu Ronaldo. Até aquele momento, não conhecia Ronaldo, conheceu naquele dia. Informou que, por ser menor, foi para o banco de trás, enquanto Ronaldo ficou no banco da frente. Narrou que, na estrada, Ikaro teria dito que precisaria parar em São José para pegar algumas roupas e, em sequência, eles iriam para Ilhabela. Quando eles chegaram na Dutra, na altura do Pedágio de Arujá, a polícia abordou o carro e fez perguntas para Ikaro, que era o condutor do veículo. Afirmou que Ikaro lhe informou naquele momento, que estava com entorpecente dentro do carro para consumo próprio, informando-lhe que teria adquirido a droga no Guarujá, no mesmo dia da data dos fatos. Narrou que indagou Ikaro porque não tinha lhe cientificado sobre a existência da droga e que ele lhe respondeu que era só para seu consumo e acelerou o carro e pegou a droga e jogou pela janela. Não sabia que tinha entorpecente dentro do veículo automotor. Afirmou que o réu Ikaro saiu aproximadamente 03 anos antes dele da prisão. Afirmou que, às vezes, usava o aparelho celular da filha, e encontrou o Ikaro no Facebook e começou a conversar com ele. Nesse período ainda não estava trabalhando, ia completar 01 mês que tinha saído da prisão. Nenhum dos aparelhos celulares apreendidos eram dele. Estava sem celular. Afirmou que viu Ikaro pela última vez antes da data dos fatos em 2015. Tem três filhas. A filha que usou o celular mora em Santo junto com a mãe do réu. Questionado sobre quem jogou

as drogas para fora do carro, esclareceu que, quando o corréu Ikaro tinha lhe dito que havia drogas dentro do carro, pediu para que ele (corrêu Marcos) pegasse uma caixa, mais ou menos do tamanho de sapato, que estava no banco de trás do carro e que se encontrava debaixo de uns cobertores. Pegou a caixa e deu na mão do corréu Ikaro, que a abriu e jogou as drogas para fora da janela. No momento em que a polícia deu a ordem de parada, ainda não sabia da existência da droga. Quando a polícia mandou encostar, o Ikaro foi andando, encostando e falou para o interrogado pegar a caixa debaixo do cobertor, momento em que Ikaro lhe informou que se tratava de entorpecente que comprou para o consumo pessoal. Esclareceu que o dinheiro apreendido dentro do carro era de Ronaldo, mas que não sabe dizer se Ronaldo colocou o dinheiro no console do carro. Informou que soube que o dinheiro apreendido era de Ronaldo no momento em que estavam na delegacia. Informou que um dos celulares apreendidos era de Ikaro e o outro era de Ronaldo. Esclareceu que na data dos fatos morava na Praia Grande. Que não sabe exatamente onde Ikaro adquiriu as drogas, mas que acha que foi no Guarujá e que foi no mesmo dia dos fatos. Ikaro pegou o interrogado por volta das 11 horas da noite. Na data da audiência, morava em Ilhabela. Atualmente trabalha como ajudante de pedreiro na empresa que pertence ao réu Ronaldo, mas quem administra, na realidade, a empresa é o pai de Ronaldo. Informou que, desde a prisão preventiva dos três réus neste processo, fez amizade com Ronaldo, que lhe ofereceu emprego. Ganha, em média R\$1.500,00 por mês. Questionado se, por ocasião das conversas que tivera com Ikaro quando saiu da cadeia, este teria lhe oferecido emprego, respondeu que não. Disse que não é usuário de drogas.

Interrogado em juízo, o réu Ronaldo Augusto Gonçalves Mariano negou os fatos constantes da acusação. Afirmou que participa de um grupo no facebook chamado de Caroneiros de Ilhabela e viu uma postagem do corréu Ikaro que estaria oferecendo uma carona para Ilhabela, sendo que ele curtiu a postagem e combinou com o corréu Ikaro a viagem cerca de meia hora antes da viagem ocorrer. Afirmou que o corréu Ikaro o pegou na Vila Mariana, na casa da ex-namorada, por volta de 20h/21h. Alegou que, quando entrou no veículo, o corréu Marcos já estava no veículo e já estava na parte de trás. Esclareceu que, até então, não conhecia nenhum dos dois corréus. Conheceu os corréus naquela ocasião. Narrou que quando chegaram no pedágio de Arujá, após os policiais fazerem perguntas na abordagem policial, o corréu Ikaro empreendeu fuga. O Ikaro pediu para o rapaz que estava no banco de trás pegar uma caixa que estava embaixo de umas roupas dele e começou a jogar as drogas para fora do carro. Disse que não ficou nenhum registro do diálogo que teve com Ikaro combinando sobre a carona. Esclareceu que o aparelho celular dele foi apreendido por ocasião dos fatos, mas que o outro não era dele. Narrou que estava com cerca de R\$1.300,00 no bolso. Aduziu que o dinheiro estava no bolso dele, mas, quando os policiais o abordaram, eles tiraram o dinheiro do bolso dele. Afirmou que só tinha esse dinheiro ali. Perguntado se ele costuma pegar carona com dinheiro no bolso, sem adotar as devidas cautelas para ver quem irá transportá-lo, afirmou que costuma andar com dinheiro em espécie, mas que também usa cartão. Disse que não é usuário de drogas e que não sabia que tinham drogas no veículo. Esclareceu que o corréu Ikaro pegou da parte de trás do carro as drogas, colocou-as no colo e que as arremessou do carro. Afirmou que, como tudo foi muito rápido, não teve tempo hábil de perguntar para o corréu Ikaro o que estava acontecendo. Informou que, depois dos fatos, acabou conhecendo os demais corréus, mas afirma que não ficaram amigos. Esclareceu que o corréu Marcos trabalhava na empresa dele como servente. Presta serviços de construção e tem um depósito de material de construção. Afirmou que, na época dos fatos, estava com a carta de motorista cassada. Tem carro. Depois que saiu da cadeia, fez a reciclagem para obter nova habilitação. Está cursando engenharia civil. Conhecia o corréu Ikaro antes dos fatos só de vista, pois já tinha o visto em Ilhabela, não sabendo com o que ele trabalhava nem o que ele fazia. Foi de Ilhabela para São Paulo por meio de carona no mesmo grupo que tinha contatado o corréu Ikaro. Narrou que levou a quantia de R\$2.000,00 em espécie, porque, para ele, não era uma quantia alta e que era para os gastos pessoais dele e costumava andar com dinheiro em espécie. Teve contato com o corréu Ikaro somente enquanto ficaram presos e depois que foram soltos não manteve mais contato, apesar

de vê-lo algumas vezes em Ilhabela. Enquanto estavam presos chegou a discutir com Ikaro, questionando o porquê de não ter lhe informado da existência da droga. Disse que Ikaro tinha mencionado que adquiriu a droga em Guarujá e que ela era destinada para o uso pessoal do próprio Ikaro.

Além disso, analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, também não ficou comprovada a autoria e a materialidade de que estes réus tenham praticado os crimes previstos nos arts. 33 e 35 na Lei de Drogas (fls. 02/04). Ambas as testemunhas, policiais que conduziram os réus à delegacia, informaram que os réus apontaram que o réu Íkaro era quem tinha conhecimento da droga transportada e que era o seu proprietário.

Os réus, em seus interrogatórios policiais, também foram uníssonos em afirmar que Marcos e Ronaldo não sabiam da existência da maconha, que pertencia ao réu Ikaro (fls. 05/07).

No mais, a perícia realizada nos celulares apreendidos 856/870 não encontrou qualquer prova que pudesse atribuir a conduta delitiva aos réus, pois um celular estava inoperante e o outro era protegido por senha e não foi possível extrair seus dados.

Por mais que em seus interrogatórios os réus Ikaro e Marcos Roberto tenham se contrariado com relação à pessoa que pegou a droga para jogar para fora do veículo, tal contradição por si só não é capaz de comprovar que o réu Marcos tinha ciência da existência de substâncias ilícitas dentro do veículo, tampouco demonstrar a sua coautoria ou participação no tráfico de drogas, ou no crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Assim, não é possível a condenação dos réus Marcos e Ronaldo por falta de provas da sua conduta delitiva, em primazia ao princípio constitucional da presunção da inocência e do "in dubio pro reo". Impõe-se, pois, a absolvição desses réus, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por outro lado, ficou comprovado que Ikaro Chamarelli praticou o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 18/22), pelo laudo toxicológico (fls. 226/228), bem como pela prova oral coligida durante a persecução penal.

Todas as testemunhas e todos os réus apontaram que a maconha encontrada no interior do veículo que o réu Ikaro conduzia era de sua propriedade. Inclusive, em seu interrogatório, o próprio réu informou que era o proprietário da droga. No entanto, sustentou que não praticou o crime de tráfico, pois pretendia consumir toda aquela substância e que ela se destinaria para seu consumo pessoal, pleiteando que sua conduta fosse enquadrada no art. 28 da Lei de Drogas.

Interrogado em juízo, o réu Ikaro Chamarelli negou os fatos constantes da denúncia. Afirmou que não é traficante; que a maconha que foi apreendida era dele para uso pessoal. Alegou que costumava comprar 500 gramas por R\$2.000,00, mas como o vendedor teria oferecido mais barato a quantidade de dois quilos de maconha, decidiu comprar, gastando R\$1.500,00 por cada quilo. Indagado por qual motivo teria saído para comprar drogas no Guarujá, e não em Ilhabela onde mora, respondeu que em Ilhabela não existe pontos de droga, aduzindo que sempre foi para o Guarujá para comprar óleo de barco e para levar o barco no Guarujá e que lá a venda de drogas é explícita. Ademais, afirmou que o motivo de ir para o Guarujá comprar as drogas foi sair para dar uma espairecida e porque ele teria aproveitado e realizado outras compras lá. Indagado se já conhecia o corréu Marcos, afirmou que o conheceu no

sistema prisional em 2015, afirmando que não conhece a filha dele. Narrou que o corréu Marcos teria entrado em contato com ele por meio do facebook e que sempre o convidava para ir para Ilhabela. Como nesse dia ia para o Guarujá, entrou em contato com Marcos para perguntar se ele queria voltar de Santos com ele para ir para Ilhabela e ele lhe respondeu que estava em São Paulo naquele dia. Afirmou que estava chovendo muito no litoral e tendo desmoronamento de barreira. Subiu para São Paulo. Já tinha pego a droga no Guarujá, momento em que estava sozinho. Pegou Marcos umas 22:30. Saiu do Guarujá por volta das 20 horas, pegou o Marcos no Jabaquara. Após publicar algo no aplicativo de carona, chamado caroneiros de Ilhabela, o corréu Ronaldo tinha dado like e ele resolveu dar carona para ele por R\$40,00 na Vila Mariana. Esclareceu que não conhecia o corréu Ronaldo, mas que eles tinham amigos em comum em Ilhabela. Afirmou que não se importou de dar carona para outras pessoas mesmo tendo consigo drogas, por ser uma coisa normal para ele. Afirmou que não tinha fumado enquanto dirigia. Apesar do uso contumaz de drogas, nunca ficou incapacitado para suas atividades e nunca ficou internado. Questionado como teria sido a abordagem policial, narrou que, estava realizando o pagamento do pedágio quando o policial teria lhe perguntado de onde ele vinha e para onde iria. Afirmou que, após o policial ter pedido para que ele parasse o carro no acostamento, como tinha ficado nervoso, acelerou e empreendeu fuga. Quando começou a acelerar o Ronaldo e o Marcos lhe perguntaram por que estava correndo. Informou que as drogas estavam na parte de trás do carro, no assoalho, na parte de trás do passageiro, aduzindo que as drogas estariam debaixo das várias roupas de propriedade da pessoa que era a dona do carro, que era emprestado. Informou que ele mesmo pegou as drogas, pois seu braço as alcançou e teria as jogados pela estrada, sem pedir para que ninguém as pegasse. Pagou R\$1.500,00 em cada quilo da droga. Esclareceu que tinha R\$32,00 e mais R\$40,00, que recebeu de Ronaldo pela carona. Afirmou que comprou a droga com dinheiro do seu trabalho. Disse que, apesar de ganhar bem, ofereceu carona a pessoas estranhas por fazer parte de um grupo de pessoas de Ilhabela que, sempre quando vai para São Paulo, por força de hábito, coloca para compartilhar a viagem. Ademais, afirmou que é uma das formas que encontrou para “enxugar” os gastos da viagem. Trabalha fazendo passeio de barco e tem pousada em Ilhabela. Não vende drogas durante o passeio. Afirmou que usaria aquela quantidade de drogas por volta de 5 ou 6 meses. Fuma em torno de quarenta a cinquenta gramas de maconha por semana. É marinheiro. Afirmou que ganha por volta de R\$9.000,00 a R\$11.000,00. Alegou que não tem nada contra os demais corréus. Esclareceu que fuma maconha todos os dias.

O intuito da traficância restou suficientemente demonstrado.

A intenção do tráfico ilícito de drogas para o réu Ikaro ficou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida, além da forma de acondicionamento, embrulhada em forma de 04 tijolos.

Por mais que o réu Ikaro alegue que tinha acabado de adquirir a substância para seu consumo pessoal, o próprio réu admitiu que se tratava de grande quantidade e que não costumava andar com essa quantia de drogas.

Além disso, alegou que consumia cerca de 40 a 50 gramas por semana. Considerando que comprou 2,2kg, teria estoque para mais de 1 ano, o que não é crível. Por mais que o réu tenha alegado que adquiriu a maconha em grande quantidade por terem lhe oferecido por preço mais barato, não são sequer verossímeis os valores apontados pelo réu.

O réu afirmou que costumava comprar 500 gramas por R\$2.000,00, então, se adquirisse 2,2kg da substância, gastaria em torno de R\$8.800,00. Portanto, não é verossímil que tenha adquirido 2,2 kg por R\$3.300,00 (já que informou que pagou R\$1.500,00 o quilo). Ora, o próprio réu aduziu que adquiriu a droga por ser “de qualidade” e por estar “na promoção”, assim, não é crível que estivesse sendo vendida por menos da metade do seu valor normal.

Aliás, como o próprio réu admitiu em seu depoimento, já foi processado por tráfico de drogas anteriormente, o que demonstra que saberia dos riscos de ser abordado na posse de grande quantidade de substâncias ilícitas. Mas, mesmo sabendo que poderia ser flagrado na posse de toda esta quantia de drogas resolveu sair de seu Município de residência em Ilhabela para adquirir a droga no Guarujá, depois ir até o Jabaquara (no município de São Paulo), em seguida à Vila Mariana (apenas para oferecer carona a um estranho), para depois passar em São José dos Campos (já que os réus informaram que Ikaro ainda pretendia passar nesta cidade para buscar roupas) e depois voltar novamente para sua cidade, Ilhabela.

Isto é, se a droga realmente fosse para seu consumo próprio, o réu se preocuparia em, logo que a adquirisse, voltar para sua residência para poder armazená-la, e não ficar transitando pelas rodovias do estado para ofertar caronas a ex-companheiro de cárcere e a indivíduo desconhecido.

Frisa-se que causa muita estranheza o réu tenha saído de seu local de residência para adquirir drogas em outra cidade do litoral e, após isso, tenha se dirigido a São Paulo (já no período noturno) para dar caronas aos corréus para depois voltar à Ilhabela.

Cabe ressaltar que para ir do Guarujá até a Ilhabela são 136 quilômetros, ao passo que se o réu fosse do Guarujá até São Paulo para depois voltar à sua cidade, percorreria 300km, ou seja, mais que o dobro da distância.

O réu justificou que desviou o percurso vindo para São Paulo porque estava em época de chuvas e caindo barreiras, porém tal justificativa não é plausível, pois para ir de São Paulo para Ilhabela o réu utilizaria a Rodovia Tamoios, também passando pela serra do mar, correndo o mesmo risco de queda de barreiras que correria se percorresse o trajeto de Ilhabela para o Guarujá.

Além disso, as circunstâncias da prisão do réu indicam que tinha ciência da gravidade de transportar a quantia de drogas que estava com ele, tanto é que, assim que lhe foi ordenado que encostasse o veículo para a revista policial, o réu tratou de empreender fuga e tentar se livrar da substância ilícita que possuía, arremessando-a pela janela do veículo.

Aliás, não há necessidade que infrator seja surpreendido no momento da venda.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim“(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347)

Assim, pelas provas dos autos, ficou demonstrado que as drogas de propriedade do réu Ikaro eram destinadas à mercancia, mormente pela enorme quantidade e pela postura do réu, quando em revista policial.

Não há impedimento de que o usuário seja também traficante.

Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

Contudo, quanto ao crime de associação, não houve prova dos elementos objetivos do tipo.

Como não ficou comprovado que os corréus praticaram o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não é possível condenar o réu Ikaro pelo delito do art. 35 da mesma lei, que tem como elementar a associação de duas ou mais pessoas para a prática dos crimes previstos no art. 33.

Não ficou comprovado o envolvimento de mais de uma pessoa no crime praticado pelo réu Íkaro. Impõe-se, pois, sua absolvição com relação ao tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Verificando-se, presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo, a ausência de causa excludente de ilicitude e de culpabilidade e a comprovação da materialidade e da autoria, a consequência que se impõe é a condenação do réu Ikaro somente no crime de tráfico e absolvição no crime de associação para o tráfico.

III. DOSIMETRIA

Determinada e certa a condenação do sentenciado IKARO, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal.

- quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade do delito está limitado à gravidade do fato;
- quanto aos antecedentes, verifico que há condenação transitada em julgado em 23/01/2013 (processo 271/2008 - fl. 770); em 05/04/2013 (processo 554/2010 - fl. 771); em 08/04/2013 (processo 0005474-41.2010.8.26.0247 - fl. 771). Assim, os dois primeiros processos serão levados em consideração para fins de maus antecedentes e este último será analisado na segunda fase da dosimetria.
- quanto à conduta social e personalidade, deixo de apreciar tais circunstâncias em razão de refletir direito penal do autor, vedado constitucionalmente;
- quanto aos motivos, estes são inerentes ao crime analisado, qual seja, ganho fácil;
- quanto às consequências, não foram coletadas provas a este respeito;
- quanto às circunstâncias, não há elementos que impliquem uma maior reprovabilidade;
- quanto ao comportamento da vítima, fica prejudicada a análise em virtude de se tratar de crime vago.

Além disso, em se tratando de crime de tráfico, há de ser analisada a natureza e a quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06.

Em relação à natureza da droga, adoto o entendimento de que aqueles que traficam cocaína, pasta-base e crack devem ter apenados de forma mais gravosa do que aqueles que traficam apenas maconha. A maconha, em muitos países, é droga de uso regulamentado e não induz, por si só, alterações graves de conduta ao usuário, ao passo que aquelas outras sempre são proibidas e provocam efeitos devastadores na vida pessoal do usuário. Assim, no caso presente, considerando-se que o sentenciado foi surpreendido com maconha, não deve haver exasperação da pena em razão da natureza da droga.

Contudo, deve-se ter em consideração a grande quantidade de droga encontrada em seu poder, o que gera uma periculosidade social mais agravada, devendo ser considerada em seu desfavor.

Sendo assim, havendo maus antecedentes e grande quantidade de drogas encontrada em poder do réu, há valoração negativa das circunstâncias judiciais. Exaspero a pena mínima em 2/8 e fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses e 28 dias de reclusão e 633 dias-multa.

No tocante à segunda fase de dosimetria, referente às circunstâncias agravantes e atenuantes, considero presente a agravante da reincidência. Com isso, agravo a pena base em 1/6 e fixo a provisória em 7 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão e 739 dias-multa. Não se verifica presente a atenuante da confissão já que esta precisa

ser integral e no caso, foi reconhecido pelo sentenciado somente a posse para uso pessoal e não para o tráfico.

Quanto à terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou de diminuição, o que permanece a pena definitiva nos moldes da provisória. Deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente e tem maus antecedentes.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo, em razão da ausência de elementos para a verificação da condição econômica do réu.

A pena privativa de liberdade do sentenciado deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, na forma prevista no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, em razão da quantidade da pena ser superior a 4 anos e pelo réu ser reincidente.

Incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para

1) ABSOLVER os réus MARCOS ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL e RONALDO AUGUSTO GONÇALVES MARIANO e IKARO CHAMARELLI do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386. VII do CPP;

2) ABSOLVER os réus MARCOS ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL e RONALDO AUGUSTO GONÇALVES MARIANO do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386. VII do CPP;

3) CONDENAR IKARO CHAMARELLI pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 dias-multa, no patamar unitário mínimo.

O réu tem o direito de apelar em liberdade, já que está em liberdade e não houve requerimento de prisão cautelar.

A alteração do regime inicial em razão de eventual detração deve obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há informações a respeito do bom comportamento do condenado neste momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Fixo os honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da tabela do convênio OAB/DP. Em caso de recurso, expeça-se certidão de 70% do valor da tabela do convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal e 30% do valor da tabela do convênio OAB/DP após o trânsito em julgado. Em caso de

ausência de recurso, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Aruja, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA